

1505890-89.2021.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Classe/Assunto: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins nº 1501798-07.2019.8.26.0114, Relator: Reinaldo Cintra, Comarca: Campinas, Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 08/09/2022, Data de publicação: 08/09/2022. Ementa: Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505890-89.2021.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505890-89.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2110952/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 12443806 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 4, 2421/20/404 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2110952 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO SANTOS MENEZES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Luciano Santos Menezes, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 29 de janeiro de 2020, por volta das 17h20, no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) II, localizado na Rodovia SP 300, Km 353, Núcleo Gasparini, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, trouxe consigo, para o tráfico ilícito, 10 porções de maconha (59,19 gramas), substância entorpecente que

causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição/apreensão (fls. 09), laudo definitivo (fls. 11/14).

Pela decisão de fls. 73/75, foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

O réu foi formalmente citado (fls. 88), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 96).

Na decisão de fls. 102/103, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 144/145 foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa. Na mesma ocasião, foi declarada a revelia do acusado.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 149/155 pugnando, em suma, pela desclassificação para o delito de consumo pessoal e posterior absolvição, por ausência de interesse de agir.

Já a Defensoria às fls. 159/163 pleiteou, em síntese, pela absolvição por atipicidade, ou a desclassificação para o delito de consumo pessoal, com a posterior absolvição nos termos requeridos pelo Parquet.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição/apreensão (fls. 09), laudo definitivo (fls. 11/14).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os agentes penitenciários Bruno Manfrinato do Carmo e Isaac Tofanello Moino, na fase judicial (mídia SAJ) disseram que, no dia dos fatos, o acusado retornava para a penitenciária, após participar de um curso de pintura. Afirmaram que ele foi submetido à busca pessoal, sendo que, nos dois bolsos da calça dele, havia uma substância parecida com maconha. Informaram que ele contou que seria para consumo próprio. Esclareceram que o réu foi submetido ao scanner corporal, descobriram que havia em seu estômago outras porções de droga (nove invólucros), sendo que ele foi imediatamente levado ao pronto socorro para a retirada da droga.

Aqui, uma ressalva.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a

imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Luciano Santos Menezes ouvido somente no procedimento disciplinar (fls. 35/36) alegou, em resumo, que é viciado em maconha. Afirmou que tentou adentrar a unidade com a droga 'para fazer uso aos finais de semana'. Informou que, no bolso da calça, tinha uma porção de maconha, sendo que também tinha engolido 9 (nove) invólucros de maconha.

Pela prova colhida, com a devida vênia a eventual entendimento em contrário, é de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Para tanto, de início, tem-se que o art. 28, §2º da Lei nº 11.343/06 preceitua que: § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

A droga foi apreendida quando o acusado retornava do presídio após um curso de pintura.

Uma das porções de maconha estava no bolso da calça do acusado.

Ocorre que as demais (9) foram engolidas por ele e retiradas após procedimento médico.

Por isso, não é razoável que o acusado tenha engolido a maioria do entorpecente, e, depois, tinha esperança de expeli-las para consumi-las em um final de semana.

A quantidade, no contexto, é incompatível com o "mero" consumo.

Aliás, em casos análogos de apreensão de droga, nas circunstâncias postas, a jurisprudência se pronunciou pela capitulação da conduta como tráfico de drogas.

Neste sentido:

"(...)Com efeito, em que pese o silêncio do apelante, o agente penitenciário CAIO FERNANDO SANTOS BARBOSA confirmou o relatado na inicial acusatória. Disse que ao retornar de seu trabalho externo ANDERSON foi submetido a exame de scanner corporal e algo foi localizado em seu estômago. (...)" (TJ-SP, Classe/Assunto: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins nº 1501798-07.2019.8.26.0114, Relator: Reinaldo Cintra, Comarca: Campinas, Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 08/09/2022, Data de publicação: 08/09/2022. Ementa: Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria demonstrada. Validade da palavra dos agentes penitenciários. Dosimetria perfeita. Sentença mantida. Recurso não provido).

Além disso, há duas condenações em detrimento do acusado (fls. 61/66 e 68/69), ambas por tráfico, representando maus antecedentes e reincidência específica.

Por tudo, há prova contundente da traficância.

Tampouco delineado o crime impossível.

Com efeito, abstratamente, seria possível que o acusado consumasse o delito (o que teria ocorrido, inclusive, antes de ser submetido ao scanner), se o aparelho, verbi gratia, não pudesse detectar as drogas.

Por isso, para além do delito ter sido consumado previamente, o meio utilizado não era inteiramente ineficaz.

No sentido:

Ementa: TRÁFICO DE DROGAS - Pleito defensivo pela absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de provas - Impossibilidade - Desconhecimento da ré que trazia junto ao corpo substância entorpecentes - Hipótese incabível - Alegada tese de crime impossível - Inocorrência - Eficácia do meio para a consumação do delito - Precedentes - Ré surpreendida tentando ingressar em estabelecimento prisional com drogas - Absolvição por falta de provas - Impossibilidade - Depoimentos convincentes e sem desmentidos - Condenação mantida - Dosimetria - Penas-base fixadas no mínimo legal - Dolo normal para a espécie e pequena quantidade de entorpecente apreendido - Confissão não caracterizada - Ré que negou soubesse estar transportando droga - Tráfico privilegiado possível - Réus primários, sem antecedentes e inexistência de informes concretos sobre eventual dedicação deles ao crime ou sobre integrarem organização criminosa - Restritiva de direitos e regime aberto para ambos os apelantes suficientes - Apelos defensivos parcialmente providos, com expedição de alvarás de solturas clausulados.

(TJSP, 2ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1500383-37.2019.8.26.0583, relator Des. André Carvalho e Silva de Almeida, julgado em 29/08/2022, g.n.)

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais (feito nº 0038710-58.2011.8.26.0405).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a pena-base deve ser exasperada em 1/6, perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o acusado é reincidente específico (feito nº 0033837-10.2014.8.26.0405).

Deste modo, a pena deve ser agravada em 1/3, atingindo 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Ainda na intermediária, o acusado não confessou o delito.

É a inteligência da Súmula nº 630 do STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Com efeito, o acusado é reincidente específico, além de portador de maus antecedentes.

Nem se fale que haveria bis in idem na utilização da reincidência na segunda fase e na derradeira, porque o instituto é utilizado de maneira diversa.

Na intermediária, a reincidência é fator para agravar a pena, já que sempre deve agravar a reprimenda, nos estritos termos do art. 61 "caput" do Código Penal, e, ressalvadas as hipóteses legais.

Já na última fase é pressuposto para negar o redutor previsto no art. 33, §4º da lei 11343/06, salientando-se que os requisitos lá plasmados são cumulativos.

A variação da diminuição na minorante é cotejada com fatores diversos, tais como quantidade e natureza da droga (quando não utilizados na primeira fase), as circunstâncias da ocorrência, a personalidade do acusado, ou seja, de modo geral, o próprio art. 42 da lei 11343/06.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual, na terceira fase da dosimetria, sopesou não apenas a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que os acusados se dedicariam a atividades

delituosas, especialmente ao narcotráfico, motivo pelo qual não há falar em bis in idem.

2. A simples reincidência dos réus já é elemento suficiente para, por si só, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse benefício aos acusados reincidentes.

3. Se ainda não houver decorrido o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior é geradora de reincidência, independentemente de ela ser ou não pela prática do mesmo delito.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1382648 / SP, por unanimidade, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/06/2019)

Na mesma fase final, presente a majorante inculpada no art. 40, III da Lei Antidrogas.

Portanto, a pena é aumentada em 1/6, totalizando 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias reclusão e 906 (novecentos e seis) dias-multa.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial fechado.

O réu Luciano é reincidente específico, além de portador de maus antecedentes.

Em acréscimo, a pena é maior do que 8 (oito) anos, o que atrai a incidência do art. 33, §2º "a" do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL, e, deste modo, CONDENO o acusado LUCIANO SANTOS MENEZES, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

O acusado respondeu ao processo em liberdade e assim poderá recorrer.

Quanto aos entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA